

要听从安排，为从犯。本案中，刘某仅邀请他人提供银行卡，既不是犯罪的实行者，又不是犯意的发出者，在犯罪中起辅助性作用，系从犯。姚某某参与了接受、转移资金的过程，虽然是实行者，但其是受犯罪团伙指挥行事，应认定为从犯。

编写人：湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院 李根

27

违法所得的认定规则

——朱某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院(2024)桂08刑终11号刑事判决书

2. 案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪

【基本案情】

2016年至2021年，张某、谢某伙同他人为非法牟利，在某矿区以烧碱溶液灌洗矿洞的方式非法开采金矿，并将金矿提炼成黄金出售。2021年8月至12月，被告人朱某某明知张某出卖的17000克黄金是非法采矿所得仍予以收购，并支付给张某6349238元。

2021年11月1日，江某、谢某1携带500克黄金到甲首饰店出售，被告人朱某某、朱某1明知江某、谢某1出售的黄金是非法采矿所得仍予以收购，并支付给谢某1、江某195430元。同月6日，被告人朱某某、朱某1收购谢某1出售的黄金1200克，并支付给谢某1435250元；同年12月20日，被告人朱某某、朱某1收购谢某1、江某出售的黄金430克，并支付给谢某1、江某158769

元。

被告人朱某某将从张某处收购的两块黄金共计2563.19克交给朱某2保管。案发后，公安机关依法从朱某2处追缴上述黄金。被告人朱某1退出谢某1卖给其的黄金共计2130.46克，已交至公安机关。

【案件焦点】

掩饰、隐瞒犯罪所得罪违法所得是获利还是全部收入。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院经审理认为：被告人朱某某、朱某1明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，他们的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。违法所得的一切财物，是指犯罪分子因实施犯罪活动，而取得的全部财物。法律和司法解释无特殊规定时，违法所得数额应当按照收益总额认定，不应扣除犯罪分子为实施犯罪行为所支出的费用。在上游犯罪非法采矿案中，追缴犯罪行为人的违法所得系用于退赔犯罪行为造成的损失；在下游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得案中，追缴被告人的违法所得系没收因实施犯罪行为而取得的全部财物。依法判决：

一、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元；

二、被告人朱某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元；

三、追缴被告人朱某某的违法所得6349238元(含扣押于公安机关的2563.19克黄金在内)，予以没收，上缴国库；追缴被告人朱某某、朱某1的违法所得789449元(含扣押于公安机关的2130.46克黄金首饰在内)，予以没收，上缴国库。

宣判后，被告人朱某某不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院经审理认为：一审判决认定事实清楚，

证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，但判决追缴违法所得的处理有误，对定罪与量刑部分予以维持，改判：

追缴上诉人朱某某、原审被告朱某1违法所得15000元，予以没收，上缴国库。

【法官后语】

对于违法所得是否包含犯罪成本，无论是刑法理论还是司法实务都没有统一的意见。有观点认为，没收违法所得不属于财产刑的范畴，不具有财产惩戒功能，违法所得应以实际获利为限。也有观点认为，《中华人民共和国刑法》第六十四条规定的违法所得是指犯罪分子违法所得的一切财物，根据文义解释，一切财物应包含犯罪成本。还有观点认为，纯获利类犯罪没有成本或成本较小，违法所得包含犯罪成本；经营类犯罪成本较大且有差异，违法所得不包含犯罪成本。以上观点都有一定的合理之处，笔者认为，广义的违法所得包括其他涉案财物，犯罪成本是否有必要扣除，要根据犯罪的具体情况评判。

一、犯罪危害的区分

从刑法体系来看，违法所得并非个罪独有，个案不仅有单纯以犯罪为牟利手段及偶然犯罪的区分，还存在情节轻重、成本及获利等差别，而社会危害是犯罪最本质的特征，不同犯罪社会危害不同，违法所得是否计算犯罪成本不能一概而论，对于社会危害越大的犯罪，制裁手段应越严厉，犯罪成本严格依法不予扣除，而对于危害不大的犯罪，若通过主刑和附加刑能达到刑罚惩治的目的，仅没收获利即可，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》区分了“违法所得”数额和“获利”数额，就是出于不同犯罪情形社会危害不同考量。本案中，朱某某、朱某1所犯的掩饰、隐瞒犯罪所得罪是下游犯罪，未侵犯他人利益，罪行较轻，且二被告人是在正常的经营活动中偶然犯罪，并非以收赃为牟利手段，犯罪行为也未妨害司法机关对上游犯罪予以查处，虽然本案犯罪数额已远超该罪情节严重基准，但整体上犯罪的社

会危害较小，与上游犯罪及其他严重侵犯他人利益的犯罪有显著的区分，没收违法所得不宜计算犯罪成本。

二、价值判断衡量

《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定属于法律规则，在适用上具有优先性，一般情况下，除非个罪有司法解释明确违法所得的范围，否则没收违法所得的范围是犯罪分子实施犯罪所得的全部收入，包括犯罪成本在内。